



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE

In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al n. 60071/2012 del R.G., pendente tra

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), *Parte_2* (c.f.

C.F._2), *Parte_3* (c.f. *C.F._3*),

Parte_4 (c.f. *C.F._4*), *Parte_5* (c.f.

C.F._5 , con l'Avv. INDACO GIANLUCA,

ATTORI-OPPONENTI

E

Controparte_1 , con l'Avv. SED MARCO,

CONVENUTA-OPPOSTA

NONCHÉ

Controparte_2 in proprio e quale mandataria di *CP_3* , con
l'Avv. FIORETTI ANDREA,

TERZA INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.

OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo - Fideiussione – Contratti bancari e finanziari.

CONCLUSIONI

Per parte opponente: Richiamati tutti gli scritti difensivi e segnatamente l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, le note 183, VI comma, nn. 1 e 2, c.p.c., tutte le documentazioni, argomentazioni e richieste, come qui riportate e trascritte, i signori

Parte_1 *Parte_3* *Parte_2* *Parte_4* e

Parte_5 chiedono, ogni contraria istanza rigettata, accogliersi le seguenti conclusioni: “(...) e) infine, sempre in via preliminare, accertata, per tutti i motivi sopra esposti, la inesistenza delle condizioni di ammissibilità richieste dall’art. 633 c.p.c. in relazione all’art. 634 c.p.c. per la concessione del decreto ingiuntivo, dichiarare nullo ed inefficace il decreto del 26 giugno 2012 n. 13053, n.r.g. 35960/2012, notificato alle date 11 luglio – 1 ottobre 2012, con cui il Tribunale di Roma ha ingiunto ai signori *Parte_1* [...], *Parte_3*, *Parte_2* *Parte_4* e *Parte_5*, in via solidale tra loro e in ragione della loro qualità di fideiussori della *Controparte_4* [...] di pagare la somma di euro 95.341,75 oltre interessi e spese della procedura; f) nel merito accertata la nullità e/o annullabilità del contratto di interest rate swap sottoscritto dalla *Controparte_4*, per tutti i motivi sopra esposti, dichiarare la nullità e/o annullabilità, ai sensi dell’art. 1939 c.c., della garanzia prestata dagli odierni oppositori e pertanto dichiarare nullo ed inefficace il decreto del 26 giugno 2012 n. 13053, n. r.g. 35960/2012, notificato alle date 11 luglio – 1 ottobre 2012, con cui il Tribunale di Roma ha ingiunto ai signori *Parte_1*, *Parte_3*, *Parte_2* [...] *Parte_4* e *Parte_5*, in via solidale tra loro e in ragione della loro qualità di fideiussori della *Controparte_4* di pagare la somma di euro 95.341,75 oltre interessi e spese della procedura; g) sempre nel merito accertata l’estinzione dell’obbligazione fideiussoria ex art. 1955 c.c., per tutti i motivi sopra esposti, dichiarare nullo ed inefficace il decreto del 26 giugno 2012 n. 13053, n. r.g. 35960/2012, notificato alle date 11 luglio – 1 ottobre 2012, con cui il Tribunale di Roma ha ingiunto ai signori *Parte_1*, *Parte_3* *Parte_2* *Parte_4* e *Parte_5*, in via solidale tra loro e in ragione della loro qualità di fideiussori della *Controparte_4* di pagare la somma di euro 95.341,75 oltre interessi e spese della procedura; h) ancora nel merito accertata l’estinzione dell’obbligazione fideiussoria ex art. 1957 c.c., per tutti i motivi sopra esposti, dichiarare nullo ed inefficace il decreto del 26 giugno 2012 n. 13053, n. r.g. 35960/2012, notificato alle date 11 luglio – 1 ottobre 2012, con cui il Tribunale di Roma ha ingiunto ai signori *Parte_1*, *Parte_3*, *Parte_2* *Parte_4* e *Parte_5*, in via solidale tra loro e in ragione della loro qualità di fideiussori della *Controparte_4* di pagare la somma di euro 95.341,75 oltre interessi e spese della procedura; i) in via riconvenzionale, invece, accertata la nullità e/o annullabilità e/o la risoluzione per inadempimento del contratto di

interest **Parte_6** , per i motivi sopra esposti, condannare, in ragione della cessione intervenuta, la **CP_1** **Controparte_1** a restituire al signor **Parte_7** la somma di euro 120.074,04 oltre rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze, previa dichiarazione di nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto; l) sempre in via riconvenzionale, accertata la ingiusta ed illegittima iscrizione di ipoteche giudiziali esorbitanti sia la ingiusta ed illegittima segnalazione degli oppositori presso la **Org_** e la **Organizzazione_2** , per i motivi sopra esposti, condannare la [...] **CP_1** a risarcire il danno non patrimoniale subito da ogni singolo oppositore che, in assenza di parametri specifici, e liquidato in via equitativa, si chiede fissare in euro 25.000,00 per ciascuno degli oppositori oltre rivalutazione e interessi legali dalla domanda al soddisfo, previa dichiarazione di nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto; m) con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio”.

Per parte opposta: nessuna conclusione.

Per la terza intervenuta: In via preliminare si riporta alle istanze ed eccezioni formulate all’udienza del 09.09.2019 e si insiste per la riconvocazione del CTU a chiarimenti sulla base delle osservazioni svolte alla detta udienza.

In via subordinata, precisa le conclusioni chiedendo:

- in via preliminare dichiararsi la nullità della CTU e disporsi la rinnovazione della consulenza con sostituzione del CTU in quanto il Consulente ha compiuto valutazioni soggettive non tecniche e fondato le conclusioni su fatti e circostanze prive di riscontro probatorio documentale (cfr. pag. 17 della perizia) formulando ragionamenti presuntivi, dichiarando la nullità del contratto wap oggetto d’indagine; declaratoria quest’ultima riservata al Giudice come eccepito all’udienza del 09.09.2019.

In via subordinata ci si riporta alle conclusioni della Banca cedente, **Controparte_1** di cui alla comparsa di risposta e fatte proprie dall’istante con l’atto di intervento ex art. 111 cpc che di seguito si riportano.

“Piaccia all’ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza od eccezione, nel merito rigettare l’opposizione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto e per l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma n. 13053/2012, nrg 35960/2012. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Fatto.

La *Controparte_1* ha chiesto ed ottenuto, nei confronti di *Parte_1* e degli altri opposenti, l'emissione di decreto ingiuntivo per la somma di € 95.341,75; tale somma era dovuta, secondo la prospettazione della ricorrente, quale saldo a debito di un contratto di *interest rate swap* sottoscritto dalla *Controparte_4* della quale gli opposenti si erano costituiti garanti.

Avverso tale decreto hanno proposto opposizione tutti gli ingiunti, formulando una serie di eccezioni preliminari e di contestazioni nel merito, in particolare deducendo la nullità, o in subordine, l'annullabilità o ancora la risoluzione per inadempimento della banca del contratto di *interest rate swap*, chiedendo conseguentemente la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché la condanna della banca al risarcimento dei danni in loro favore.

Si è costituita l'opposta *Controparte_1*, contestando tutto quanto ex adverso dedotto.

Nelle more del giudizio intervenivano ex art. 111 c.p.c. alcuni soggetti quali cessionari del credito vantato dalla *CP_1* e, da ultimo, la *Controparte_2*

La causa è stata istruita tramite audizione di testimoni e CTU; all'esito, dopo diversi rinvii dovuti anche al mutamento del giudice titolare del fascicolo, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 17.12.2021 (svoltasi mediante trattazione scritta ex art. 221 comma 4 L. 77/20), previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..

Diritto.

Preliminarmente occorre prendere atto che gli attori-opponenti non hanno più riproposto l'eccezione pregiudiziale di difetto di procura (che risultava comunque emendata ex art. 182 c.p.c. sin dalla costituzione dell'opposta, con la produzione del documento comprovante i poteri del soggetto che ha conferito il mandato alle liti per conto della *Controparte_1*).

Come pure hanno espressamente abbandonato le domande di cancellazione delle ipoteche e della segnalazione degli opposenti al *Org_1* su tali domande, invero, si deve rilevare la cessazione della materia del contendere, atteso che sia le iscrizioni pregiudizievoli sia la segnalazione alla centrale allarme interbancaria sono state cancellate sin dal 2014, a seguito del pagamento volontario, da parte degli opposenti, delle somme in allora dovute in forza del decreto ingiuntivo opposto.

Ciò premesso, è fondata e deve essere accolta la domanda principale di nullità del contratto di *interest rate swap* (d'ora in avanti, per brevità, anche IRS o swap) per mancata indicazione e pattuizione degli elementi essenziali e per mancanza di una causa in concreto meritevole di tutela, e, dunque, per violazione degli artt. 1418, 1346 e 1322 c.c..

In proposito, vista anche la frequenza di tali contratti nella prassi bancaria e finanziaria, si è ormai formata un'ampia giurisprudenza, che ha visto anche pronunce della Cassazione, persino a Sezioni Unite.

Su tutte, merita di essere richiamata la nota sentenza delle SSUU, n. 8770 del 12/05/2020, la quale, pur pronunciata in materia di contratti derivati sottoscritti dagli enti locali, ha espresso principi generali applicabili tendenzialmente a tutti i contratti del medesimo tipo (e, del resto, esaminando la fattispecie concreta oggetto del giudizio, emerge che si trattasse proprio di un contratto analogo a quello per cui è causa).

La Suprema Corte ha, innanzi tutto, fornito una descrizione di massima delle caratteristiche del contratto, precisando che: *«l'“interest rate swap” è un contratto derivato, le cui caratteristiche sono: a) è “over the counter”, vale a dire ha un contenuto fondamentale non eteroregolamentato, ma deciso dalle parti sulla base delle specifiche esigenze dell'interessato; b) è non standardizzato e, quindi, non destinato alla circolazione, essendo privo del requisito della cd. negoziabilità; c) l'intermediario è in una situazione di naturale conflitto di interessi poiché, assommando le qualità di offerente e consulente, è tendenzialmente controparte del proprio cliente. Elementi essenziali di tale derivato sono la data di stipulazione, quelle di inizio di decorrenza degli interessi, di scadenza e di pagamento, nonché il capitale di riferimento (cd. nozionale) ed i diversi tassi di interesse ad esso applicabili»*; ha poi evidenziato che: *«la causa dell'“interest rate swap”, per la cui individuazione non rileva la funzione di speculazione o di copertura in concreto perseguita dalle parti, non coincide con quella della scommessa, ma consiste nella negoziazione e monetizzazione di un rischio finanziario, che si forma nel relativo mercato e che può appartenere o meno alle parti, atteso che tale contratto, frutto di una tradizione giuridica diversa da quella italiana, concerne dei differenziali calcolati su flussi di denaro destinati a formarsi durante un lasso temporale più o meno lungo ed è espressione di una logica probabilistica»*; sulla base di tali premesse, le Sezioni Unite hanno quindi stabilito il principio di diritto secondo cui: *«occorre accertare, ai fini della validità del contratto, se si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell'alea, calcolata*

secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi; tale accordo non si può limitare al “mark to market”, ossia al costo, pari al valore effettivo del derivato ad una certa data, al quale una parte può anticipatamente chiudere tale contratto od un terzo estraneo all’operazione è disposto a subentrarvi, ma deve investire, altresì, gli scenari probabilistici e concernere la misura qualitativa e quantitativa della menzionata alea e dei costi, pur se impliciti, assumendo rilievo i parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dall’intesa, che sono determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo».

I principi espressi dalla Cassazione sono stati recepiti dalla giurisprudenza di merito, che in alcuni casi aveva anche già anticipato la soluzione interpretativa della Suprema Corte (cfr. tra le tante, Trib. Bari, sent. n. 3534/2021 dell’8.10.2021; Trib. Roma 3.03.2020, sent. n. 4658/2020; Trib. Roma 8.02.2021; Trib. Milano, sent. n. 6157/2021 del 14/07/2021 ed Appello Torino 10.06.2021, entrambe sulla essenzialità dell’indicazione del mark to market; tutte le pronunce sono pubblicate sulla rivista giuridica online [Org_3](#) ; a volte si è persino sostenuta la nullità del contratto per difetto di causa, in ipotesi di mancata prova della finalità di copertura di un rischio già assunto dalle parti (come nel caso molto diffuso di IRS stipulato per elidere i rischi dell’oscillazione dei tassi di mercato), ovvero in caso di esistenza di uno squilibrio originario in favore della banca (contratto c.d. “non par”).

Nel caso di specie, l’istruttoria ha accertato le carenze dei suddetti elementi essenziali nel contratto di IRS oggetto di causa.

Sono assolutamente destituite di fondamento le contestazioni e critiche mosse dalla difesa convenuta (e della terza intervenuta), alla CTU svolta dal dr. [Persona_1](#) in primo luogo, si osserva come le difese si sono limitate, in maniera anche abbastanza generica, a contestare che il consulente avrebbe tratto delle conclusioni fondate su deduzioni o presunzioni meramente soggettive e non ancorate a dati oggettivi e documentali, senza però nello specifico indicare quali punti e passaggi della relazione sarebbero affetti da tale vizio.

Il CTU, al contrario, ha fondato le sue valutazioni sulla documentazione allegata in atti (in buona parte prodotta o comunque formata dalla stessa banca opposta, come ad esempio gli estratti conto, oltre ovviamente al contratto scritto di IRS ed al contratto-quadro, nonché a quello di mutuo in essere tra le stesse parti) ed ha tratto le sue conclusioni sulla base di analisi tecniche ed anche di calcoli aritmetici-matematici (come ad esempio, laddove ha rilevato la presenza di un originario “mispricing”), valutazioni e calcoli che non sono stati idoneamente

contrastati o smentiti dalla difesa opposta (né da quella della terza intervenuta), che non ha nemmeno ritenuto di avvalersi di un proprio consulente di parte e non ha quindi opposto alcuna argomentazione tecnica specifica contraria alle risultanze della CTU.

Disattesa, quindi, l'eccezione di nullità della consulenza e la conseguente richiesta di rinnovazione delle operazioni, per quel che qui più interessa, il CTU ha rilevato quanto segue, sulle caratteristiche del contratto in oggetto: *«L'operazione derivata presenta una durata di 3 anni, con data iniziale il 12/7/07 e scadenza finale il 12/7/10; il capitale di riferimento, pari inizialmente ad € 400.000, è crescente secondo un determinato piano di ammortamento, con liquidazione semestrale dei differenziali. L'operazione presenta la struttura di un derivato "plain vanilla" che consente alla Società, a fronte dell'Euribor 6 mesi ricevuto con cadenza semestrale dalla CP_1 di corrispondere alla medesima scadenza un tasso fisso annuo [...]. Tale tipologia di derivati risulta comunemente utilizzata a fini di copertura dall'oscillazione dei tassi di interesse in quanto consente di trasformare in tasso fisso una sottostante esposizione debitoria a tasso variabile. Anche se nella documentazione non è espressamente precisato, il derivato in parola risulta posto in essere a copertura del contratto di mutuo di € 4.960.000 stipulato in data 10/7/07 con la medesima CP_1 .*

A proposito dei derivati plain vanilla con scopo di copertura di un rischio di oscillazione eccessiva di tassi variabili, il consulente d'ufficio ha evidenziato che *«affinché la copertura offerta dal derivato sia efficace è necessario che sia presente un'elevata correlazione tra l'oggetto della copertura (passività del cliente) e lo strumento di copertura (contratto derivato)»*, citando, sul punto, le determinazioni ed indicazioni della CP_5 di cui alla Comunicazione n. DI/99013791 del 26.02.1999 (delibera, come si vedrà meglio oltre, indicata anche dalla Cassazione quale parametro per la valutazione di validità e meritevolezza di un contratto di IRS); il CTU ha dunque rilevato, sotto questo profilo, che *«nella fattispecie in esame nonostante sia presumibile con certezza la funzione di copertura del derivato al contratto di mutuo (allegato n. 4 del fascicolo depositato innanzi al Tribunale di Ancona da parte attrice) non risulta verificabile con assoluta certezza l'esistenza di un'elevata correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso di interesse, tipologia, ecc.) dell'oggetto della copertura e dello strumento finanziario utilizzato a tal fine a norma dell'art. 21 TUF e dell'art. 26 del Regolamento Consob n. 11522.*

Non risulta infatti possibile confrontare le condizioni economiche del mutuo e quelle del derivato e gli eventuali allineamenti con riferimento alla rilevazione del tasso variabile che la

Società riceve dalla Banca nel contratto derivato e che dovrebbe coprire, al netto dello spread, il tasso variabile (o fisso) corrisposto dalla Società nel contratto di mutuo.

In particolare nel contratto swap la CP_1 riconosce alla Società il tasso Euribor 6 mesi rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente l'inizio di ciascun periodo, mentre nel contratto di mutuo la definizione della misura del tasso annuo nominale viene rimandata "...in sede di stipulazione dell'unico o dei singoli contratti definitivi...", contratti definitivi che non risultano presenti in atti.

Inoltre, non risulta allegato al contratto di mutuo il piano di ammortamento e lo sviluppo di quest'ultimo, riscontrabile dalle condizioni indicate in contratto, non consente di rilevare la corrispondenza tra il piano di ammortamento del mutuo adottato ed il piano di ammortamento del nozionale del derivato (3 anni).

Si rileva che il suddetto disallineamento e quindi l'imperfezione della copertura offerta dal contratto swap non risulta comunicata alla Società, né risulta che alla stipula sia stata rappresentata la diversa parametrizzazione».

Ancora, dall'analisi approfondita del meccanismo contrattuale, il CTU ha concluso come il contratto de quo avrebbe consentito alla società "di avere una copertura in caso di rialzo dei tassi superiori rispettivamente alle tre scadenze a 4,60%, 4,80% e 5,20%. Pertanto, la Società riceve dei benefici solo per un ristretto range di valori dell'Euribor 6M", il che costituisce un ulteriore elemento di squilibrio in favore della banca.

Il CTU ha poi stimato il valore di mercato dell'operazione al momento della stipula (10/7/07), evidenziando un mispricing di € 46.049, precisando e sottolineando che «il pricing del contratto evidenzia pertanto uno sbilancio (€ 46.049) degli impegni a carico della Società che, in assenza di up-front, corrisponde al margine trattenuto dalla CP_1 pari allo 11,5% del nozionale iniziale di riferimento (€ 400.000,00). Di detto mispricing, che esprime il margine di intermediazione per il servizio prestato, non è stata fornita alcuna informazione alla Società. Tale valore negativo per il cliente rappresenta un vero e proprio costo di cui lo stesso non ha contezza poiché la relativa manifestazione finanziaria non è immediata ma incorporata nei successivi pagamenti periodici [...] Detto importo rappresenta il valore del derivato alla data di stipula (mark to market) e corrisponde al margine trattenuto da CP_1 [...] per il servizio prestato il quale, dalla documentazione disponibile esaminata, non risulta rappresentato alla Società»; ancora, il CTU ha rilevato, nel caso di specie, "l'assenza

dell'indicazione delle modalità di calcolo del mark to market" e quindi, non solo del costo iniziale del contratto, ma anche del valore dell'intera operazione.

Ribadito che le conclusioni del CTU sono tratte dall'analisi completa della documentazione in atti, nonché da calcoli e stime matematiche, prive di vizi scientifici e logici, è quindi evidente come sussista la nullità del contratto di interest rate swap oggetto di causa, per lo meno sotto due profili: in primo luogo, per omessa esposizione, indicazione e pattuizione di alcuni degli elementi essenziali del negozio e, segnatamente, del costo dell'operazione (mark to market ed iniziale mispricing) e dei metodi di calcolo del valore di volta in volta assunto nel corso del rapporto; in secondo luogo per mancanza di idonea causa in concreto, o meglio per assenza di meritevolezza del contratto atipico, dal momento che – a fronte della omessa specifica pattuizione di elementi essenziali e di prova dei criteri di collegamento con l'operazione di finanziamento a copertura della quale era stato stipulato lo swap, nonché dell'iniziale squilibrio rilevato dal CTU – il contratto in questione risulta avere natura meramente aleatoria e speculativa.

In proposito è bene ricordare un altro importante arresto della Cassazione in materia di contratti derivati, secondo cui: *«in tema di meritevolezza degli interessi perseguiti con contratti atipici ex art. 1322 c.c., in particolare per i contratti c.d. “derivati”, l'art. 21 TUF e l'art. 26 Reg. Consob n. 11522/1998 hanno portata imperativa e inderogabile anche in applicazione dei principi della direttiva 93/22/CEE, prescrivendo che gli intermediari si comportino con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e dell'integrità del mercato. (Nella specie, riguardante contratti derivati “interest rate swap” con natura di operazioni “di copertura”, la S.C., in applicazione dell'esposto principio, ha cassato la sentenza di appello, richiamando altresì specificamente il rispetto delle condizioni di cui alla determinazione CP_5 26 febbraio 1999, evidenziando la necessaria stretta correlazione tra l'operazione di “copertura” e il rischio da coprire)»* (Cass. sez. 1, n. 19013 del 31/07/2017; conforme Trib. Roma 8.02.2021 cit.).

È quasi superfluo sottolineare che, avendo la banca opposta agito in sede monitoria per far valere un credito derivante da un contratto, era suo onere dimostrare non solo l'esistenza, ma anche la validità di tale contratto, tanto più alla luce delle esplicite e specifiche eccezioni sollevate dagli oppositori.

Del resto, che gli elementi essenziali del contratto (non indicati nella pattuizione scritta) non siano stati nemmeno illustrati e spiegati verbalmente alla parte contraente, è emerso sia dalla

CTU (pag. 19, penultimo capoverso della relazione “non risulta in atti che la CP_1 abbia fornito, prima dell’esecuzione delle operazioni, informazioni specifiche sulle caratteristiche del contratto swap in parola, come prescritto dall’art. 31 del citato Regolamento Consob n. 16190/07”), sia dalle testimonianze assunte all’udienza del 14.04.2015; in particolare, si vedano le dichiarazioni del teste Testimone_1 che ha così affermato: «quel giorno avevo accompagnato il Sig. Pt_1 in banca che voleva fare la richiesta di un mutuo a tasso fisso per l’attività commerciale dell’Edilizia. La pratica del mutuo era già stata concordata. Una donna gli sottopose dei moduli da sottoscrivere che spiegò allo Pt_1 in poco tempo. Io erto convinto che si trattasse soltanto del mutuo però ricordo che il funzionario parlò anche di un contratto di swap»; «andammo in banca insieme anche il giorno dopo. Ricordo che Pt_1 firmò il contratto ma la signora del giorno prima non si dilungò in spiegazioni sul contenuto del documento» ... «ricordo che firmò più fogli senza lunghe spiegazioni da parte della funzionaria».

Tale omessa o incompleta informazione, integrerebbe peraltro anche gli estremi della violazione degli obblighi gravanti sull’intermediario ex artt. 21 e 23 TUF, con conseguente fondatezza della domanda subordinata di risoluzione del contratto (che però, ovviamente, resta assorbita dalla ritenuta nullità).

La nullità del contratto, ovviamente, determina l’assenza di causa del pagamento richiesto dalla banca in sede monitoria, fondato proprio su tale contratto, dovendosi pertanto sul punto accogliere l’opposizione e revocare integralmente il decreto ingiuntivo.

Deve anche di conseguenza accogliersi la richiesta formulata dal sig. Parte_3 – quale cessionario del credito della Controparte_4 – di restituzione della somma risultante a debito della società in forza dell’invalido contratto di IRS.

Sul punto, in primo luogo l’opponente ha dato piena prova documentale della propria legittimazione attiva, producendo l’accordo di cessione di credito (persino con la prova del pagamento del corrispettivo da parte del cessionario) e la sua notifica ex art. 1264 c.c. al debitore ceduto (doc. 16 allegato all’atto di citazione), aspetto peraltro mai contestato dalle controparti.

In secondo luogo, in relazione al *quantum* dovuto, si ritiene corretta la quantificazione operata dalla parte attrice, e confermata dal CTU, sulla base dell’esame degli estratti conto elaborati dalla stessa CP_1 per il rapporto *de quo*, costituita dal saldo tra gli accrediti e gli addebiti nei confronti della società operati in esecuzione del contratto di interest rate swap.

La contestazione mossa dalla difesa della ^{Contr} sul punto, secondo cui l'eventuale perdita derivante dall'IRS dovrebbe essere determinata in relazione al rapporto complessivo tra le parti e, in particolare, al contratto di mutuo a copertura del quale era stato stipulato lo swap, è, innanzi tutto, tardiva, in quanto formulata per la prima volta soltanto nella comparsa conclusionale, mentre nei precedenti atti difensivi nessuna eccezione, contestazione o difesa di sorta era stata avanzata dalla convenuta-opposta (che non ha nemmeno depositato le memorie 183 c.p.c. e le cui difese, quindi, sono definitivamente cristallizzate in quelle esposte nella comparsa di costituzione e risposta).

In ogni caso, la contestazione è priva di qualunque riscontro probatorio (e, prima ancora, di allegazione), non avendo la parte fornito la documentazione necessaria, né tanto meno indicato quale avrebbe dovuto essere il metodo alternativo di calcolo da applicare.

Deve quindi accogliersi la quantificazione operata dagli opposenti, e confermata dal CTU, in **€ 120.068,05**, per sorte capitale; su tale somma, che costituisce debito di valuta, in quanto restituzione di un importo determinato, spettano gli interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c., dalla data della messa in mora (da individuarsi nella lettera ricevuta il 22.03.2010, doc. 9 del fascicolo di parte opponente, ove per la prima volta viene formalizzata la richiesta di restituzione della somma predetta).

Con specifico riferimento alla posizione dei garanti, poi, la riconosciuta nullità del contratto principale determina la insussistenza anche dell'obbligazione accessoria.

Invero, non si ravvisano elementi idonei per poter qualificare le garanzie prestate dagli odierni opposenti quali contratti autonomi, piuttosto che fideiussioni: oltre al dato testuale per cui in tutto il documento e nelle clausole si usano sempre i termini "fideiussione" e "fideiussore", si rileva come manchi la tipica pattuizione del contratto autonomo, secondo cui la garanzia resta valida anche in caso di invalidità o annullamento del contratto principale; la sola clausola di cui all'art. 6, si limita a prevedere il pagamento a prima richiesta, senza ulteriori impedimenti o limitazioni alla facoltà del garante di opporre eccezioni, sicché può ben essere qualificata come una semplice clausola *solve et repete* accedente ad una fideiussione; mancano, ancora, in tutta la regolamentazione contrattuale, deroghe ad alcune norme e principi caratteristici della fideiussione, quali gli artt. 1945, 1955 e 1957 c.c.. A questo proposito, sfugge francamente a quale documento si riferisca la difesa del terzo intervenuto nella propria comparsa conclusionale (pag. 15), ove richiama l'art. 5 del doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione, mentre le lettere di fideiussione per cui è causa e le relative condizioni

contrattuali sono allegate al doc. 8 del fascicolo monitorio e nell'art. 5 delle condizioni di contratto, come detto, non è prevista alcuna deroga espressa ai predetti articoli.

Ne consegue che, dichiarato nullo il contratto dal quale deriva il debito principale, ed essendo quest'ultimo inesistente, i garanti non possono ritenersi obbligati nei confronti della banca; sarebbe peraltro anche fondata l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., che come visto è norma applicabile al caso di specie in quanto non derogata dal contratto (in proposito, non è stata mai contestata la ricostruzione offerta in citazione sulla data di maturazione del debito e dunque sulla decorrenza del termine per l'escussione ex art. 1957 c.c., termine che del resto coincide con la scadenza del contratto di IRS).

Da ultimo, si rileva come – ove anche si volesse ritenere la natura di contratti autonomi di garanzia delle fideiussioni prestate dagli opposenti – la giurisprudenza è in ogni caso pacifica nel ritenere che il garante è pur sempre legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative (Cass. sez. 1, n. 371 del 10/01/2018; n. 20397 del 25/08/2017; sez. 3, n. 5044 del 3/03/2009), come nel caso di specie.

Deve quindi sicuramente essere accolta la domanda riconvenzionale dei garanti, di restituzione delle somme da loro versate nel 2014, a soddisfazione del credito ingiunto; invero, a verbale di udienza del 9 maggio 2014, si è dato atto che gli opposenti hanno versato all'opposta la complessiva somma di € 102.179,62 (di cui € 95.341,75 per capitale, € 4.622,09 per interessi ed € 2.215,82 per spese legali, così come liquidate nel decreto ingiuntivo opposto), al solo fine di ottenere l'immediata cancellazione delle ipoteche giudiziali e della loro segnalazione alla *Organ* agli altri archivi dei "cattivi pagatori". Tale somma, versata in forza di un credito riconosciuto inesistente e di un decreto ingiuntivo qui revocato, dovrà quindi essere restituita agli opposenti, con gli interessi ai sensi dell'art. 1284 c.c. dalla data del pagamento al saldo effettivo.

Occorre ovviamente precisare che entrambe le condanne al pagamento di somme devono essere rivolte alla originaria convenuta-opposta *Controparte_1*, essendo quest'ultima che ha ricevuto gli indebiti pagamenti e non anche il terzo intervenuto, che si è soltanto reso cessionario della obbligazione attiva (come visto, invalida e non esistente).

Sono invece infondate e da rigettare le domande di risarcimento dei danni asseritamente subiti dagli opposenti a causa delle ipoteche iscritte dalla banca in forza del decreto ingiuntivo ed a causa della segnalazione degli stessi garanti nel sistema di allarme interbancario.

Come visto, infatti, entrambe le iscrizioni e segnalazioni pregiudizievoli sono state cancellate o eliminate sin dal maggio 2014, e, per il periodo in cui sono state in essere, non è stato provato e prima ancora allegato in concreto alcun danno effettivamente subito dagli opposenti.

Ricordato che, condivisibilmente, la giurisprudenza ha ormai da tempo abbandonato il concetto di danno *in re ipsa* per alcune ipotesi di condotte illecite, e che, quindi, anche laddove sia richiesto il risarcimento di un danno non patrimoniale, il ricorso alla liquidazione equitativa è possibile soltanto in relazione al *quantum* e non anche all'*an*, che deve sempre essere allegato e provato da chi agisce in risarcimento, nel caso di specie gli opposenti non hanno assolto a tale onere, non avendo dedotto alcun danno patrimoniale (ad esempio, per non aver potuto accedere al credito bancario o per aver perso finanziamenti già ricevuti o affari la cui conclusione dipendeva dalla concessione di un mutuo bancario, o ancora la perdita di occasioni di vendita degli immobili ipotecati), limitandosi a dedurre un generico danno non patrimoniale all'immagine – per essere stati segnalati al sistema bancario quali clienti inaffidabili – che però è completamente privo di riscontri probatori.

Non si ritengono sufficienti, sul punto, alcune lettere di altre banche indirizzate agli opposenti che chiedono spiegazioni in relazione all'iscrizione di ipoteche, in quanto alle stesse aveva risposto il legale degli opposenti, fornendo chiarimenti sulla vicenda e risultano prive di ulteriori seguiti.

Spese di lite.

Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte opposta e del terzo intervenuto, in solido tra loro, nella misura liquidata in base ai parametri di cui al DM 10.03.2014, n. 55 – tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta e dell'aumento per la difesa di più parti – in complessivi € 16.000,00 (di cui € 3.000,00 per la fase di studio, € 2.000,00 per quella introduttiva, € 6.000,00 per la fase istruttoria ed € 5.000,00 per la decisionale), oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge; agli attori-opponenti spetta anche il rimborso delle spese vive per € 338,00 (contributo unificato e diritti di cancelleria).

Anche le spese di CTU, come già liquidate con decreto del GI, devono essere definitivamente poste a carico della convenuta-opposta e della terza intervenuta, con conseguente diritto delle

altre parti alla restituzione di quanto abbiano eventualmente versato al consulente a titolo di acconto pro quota.

P.Q.M.

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 60071/2012, ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata così provvede:

- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità del contratto di interest rate swap concluso tra la *Controparte_1* e la *Controparte_4* in data 10.07.2007;

- revoca il Decreto Ingiuntivo n. 13053/2012, emesso nel procedimento monitorio NRG 35960/2012;

- in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali degli opposenti, condanna la *Controparte_1* al pagamento, in favore di *Parte_3*, della somma di € **120.068,05**, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla messa in mora (22.03.2010) al saldo effettivo;

- condanna la *Controparte_1* al pagamento, in favore di *Parte_1*, *Parte_3*, *Parte_2*, *Parte_4* e *Parte_5*, in solido tra loro della somma di € 102.179,62, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dal 9 maggio 2014 al saldo effettivo;

- rigetta le domande riconvenzionali di risarcimento del danno avanzate dagli opposenti;

- condanna la parte opposta *CP_1* e la terza intervenuta *Controparte_2*, in solido tra loro, alla refusione, in favore degli attori, in solido tra loro, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 16.000,00, oltre accessori di legge, per compensi, ed € 338,00 per rimborso spese vive;

- pone le spese di CTU, come già liquidate con decreto del GI, definitivamente a carico della parte opposta e della terza intervenuta, in quota uguale per ciascuna di esse.

Così deciso in Roma, in data 25/06/2022.

Il Giudice
Dr. Mario Coderoni